

1509908-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509908-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509908-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIEL DOS SANTOS TEIXEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DENIEL DOS SANTOS TEIXEIRA e DARIO EVANGELISTA DA SILVA foram denunciados e se veem processados pela prática do delito descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", ambos do Código Penal, porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 04h11min, durante o repouso noturno, na Rua Arroio Hondó, nº 16, Ipiranga, nesta Cidade e Comarca, em plena vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito comum, 41 (quarenta e uma) garrafas de vinho, avaliadas em R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), pertencentes ao estabelecimento ID Vinhos MR Comércio Produtos Alimentícios, representado por Ronaldo Ribeiro Santana. Recebida a denúncia, os acionados foram citados pessoalmente, apresentando resposta escrita à acusação, sendo proferida, em seguida, decisão saneadora. Em audiência, foi colhida a prova oral e interrogados os acusados. Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais. Laudo pericial do local dos fatos, a fls. 137/142. É o relato do quanto necessário. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01/02, do Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, do Auto de Exibição e Apreensão, acostado a fls. 13 e do Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 137/142.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das testemunhas e do representante da vítima.

Interrogados na etapa policial, ambos os réus silenciaram, atitude que não se espera daqueles que se dizem inocentes (fls. 06 e 07).

Em Juízo, confessaram a prática criminosa sem rodeios.

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Chamado a prestar declarações em Juízo, o representante da empresa vítima, Ronaldo Ribeiro Santana, declarou que é proprietário de uma distribuidora de bebidas e que, na madrugada dos fatos, foi acionado por policiais militares que surpreenderam, a poucos metros de distância de sua empresa, dois homens carregando caixas de vinhos de seu estabelecimento comercial. Disse que não presenciou o crime ou a abordagem policial, mas que, para ingressarem no estabelecimento, os criminosos arrombaram uma porta metálica ali existente. Encaminhando para a Delegacia de Polícia indicada, reconheceu as garrafas de vinho apreendidas com os suspeitos como pertencentes ao seu comércio.

Amparando suas palavras, temos, então, as declarações firmes das testemunhas policiais envolvidas com a prisão em flagrante dos acusados.

Chamados a depor em Juízo, Lara Lima de Almeida e Lucas Rodrigues da Silva Oliveira, narraram, em versões absolutamente parelhas, que estavam em patrulhamento de rotina, quando, pela madrugada, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, já que carregavam caixas de peso, aparentemente, e, ao notarem a presença da viatura, demonstraram nervosismo. Assim, procederam à abordagem deles, identificando-os como DENIEL DOS SANTOS TEIXEIRA e DARIO EVANGELISTA DA SILVA.

Declararam as testemunhas que os suspeitos negaram tê-las subtraído, todavia, não souberam explicar a origem das caixas, dentro das quais havia diversos vinhos. Ato contínuo, um transeunte lhes disse sobre a existência de uma distribuidora de bebidas ali próximo, para onde se dirigiram, oportunidade em que o furto foi confirmado, vez que a porta metálica principal fora arrombada pelos criminosos. Em seguida, o proprietário de tal estabelecimento foi acionado, confirmando a propriedade daqueles vinhos. Declararam, por fim, que o local de onde foram furtados os vinhos ficou preservado para perícia.

Nesta oportunidade, ambas as testemunhas policiais reconheceram os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os dois indivíduos que, nas circunstâncias acima, surpreenderam na posse de caixas de vinhos de propriedade do estabelecimento vítima.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar os acionados, sabendo se tratar de pessoas inocentes.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar os acusados.

Da mesma forma em relação à palavra do representante da vítima, que também não conhecia os réus anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-los.

Assim, analisando a prova em seu conjunto, dúvida não me paira de que os ora acusados, no dia e horário descritos na Denúncia, vale destacar, durante período de repouso noturno (por volta das 04 horas da manhã), unidos entre si em comunhão de esforços e identidade de propósitos, dirigiram-se à distribuidora de bebidas em questão e de lá subtraíram 41 (quarenta e um) vinhos, avaliados no total de R\$ 21.000,00, produtos estes na posse dos quais foram presos em flagrante.

Os bens foram apreendidos e restituídos ao proprietário da empresa vítima, sendo por ele reconhecidos.

Vale asseverar que o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº

519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTCRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTCRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTCRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTCRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTCRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTCRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTCRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTCRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJDTCRIM 34/309).

Doutro lado, não forneceram os réus qualquer explicação minimamente plausível para legitimar o encontro dos bens na posse direta de ambos.

Neste quadro, verifico que as provas são contundentes e militam em extremo desfavor dos acusados, mormente quando não conseguiram fornecer explicação idônea para justificar a situação absolutamente incriminadora na qual foram surpreendidos.

Assim, uma vez verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

Em que pese tenha o produto criminoso sido restituído à vítima, o crime chegou a se consumir, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, na medida em que a res furtiva já se encontrava na posse dos réus quando estes foram presos. Ainda que com os bens tenham permanecido por breve espaço de tempo, tal fato não configura a tentativa, na medida em que, como dito, o delito já havia se consumado.

No que tange à qualificadora da comparsaria, as provas contidas nos autos demonstraram terem os réus agido unidos em comunhão de esforços e identidade de desígnios, mormente porque, quando abordados, estavam ambos em posse direta dos bens recém-subtraídos, cada qual carregando consigo parte das caixas contendo os vinhos furtados. De tal modo, resta bem caracterizado o concurso de pessoas.

Outrossim, de rigor o reconhecimento da qualificadora decorrente do rompimento de obstáculo, na medida em que o Laudo Pericial de fls. 137/142 bem demonstra o arrombamento da porta metálica do estabelecimento vítima, por onde certamente passaram para acessar o interior do comércio e de lá subtrair os bens.

Finalmente, incide, ainda, a majorante do repouso noturno.

Desimportante, no caso, que o fato tenha ocorrido em estabelecimento não residencial, notadamente porque a prática do delito durante a madrugada evidencia a maior vulnerabilidade do patrimônio.

Consigo, outrossim, não haver incompatibilidade entre o reconhecimento da forma

qualificada do crime de furto e a incidência da causa de aumento decorrente da prática do fato durante o repouso noturno.

Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos."

E não é outro, diga-se, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal acerca do tema: "1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) - como se sabe o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática."

Destarte, sem prejuízo da configuração do crime na forma qualificada, reconheço, também, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do cometimento do delito durante o repouso noturno.

Desta forma, devem responder os acusados pela prática de um crime de furto, consumado, majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo.

Bem divisadas as responsabilidades dos acionados, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa da dosimetria, as circunstâncias do crime são absolutamente normais.

Desta forma, fixo as penas base, para cada acusado, no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a dez dias multa.

Em segunda fase, de se ver que ambos são duplamente reincidentes, inclusive específicos, DENIEL ostentando condenações definitivas por furto qualificado e por crime de falsa identidade (proc. 0078623-98.2018 e proc. 0002802-37.2014 - fls. 93/96) e DARIO havendo contra si duas condenações por furto qualificado (proc. 0023761-95.2009 e proc. 0085685-97.2015 - fls. 103/105), não transcorrido o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Revedor posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, improvable, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se

mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Doutro lado, confessaram o crime.

Desta forma, forte no disposto no art. 67, do Código Penal, exaspero as penas de ambos os acusados, unicamente, no equivalente a 1/6, para fixar, nesta etapa, o cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro de reclusão e pagamento de onze dias multa, para cada réu.

Por fim, em terceira fase, ausentes causas de diminuição de penas, de rigor sejam aumentadas em 1/3, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal, em razão do cometimento do crime em período de repouso noturno, conforme fundamentado.

Penas finais para cada um dos acusados: O cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos, um mês e dez dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quatorze dias multa, fixados no valor unitário mínimo.

Ambos os sentenciados cumprirão a pena corporal a cada qual imposta no regime inicial fechado, em se tratando de acusados duplamente reincidentes, inclusive específicos, tudo a revelar que suas anteriores condenações não foram suficientes para dissuadi-los da senda criminoso, neste momento devendo ambos receber tratamento mais severo, eis que não se mostram intimidados pela Justiça, o que demonstra a insuficiência de regime de cumprimento de penas mais brando.

Não há espaço para a substituição da reprimenda corporal aplicada aos réus por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, em se tratando de acusados duplamente reincidentes em crime doloso, inclusive de maneira específica.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual dos acionados, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR os réus DENIEL DOS SANTOS TEIXEIRA e DARIO EVANGELISTA DA SILVA, cada qual, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos, um mês e dez dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a quatorze dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo previsto em lei, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ambos os réus, e ainda mais agora, tendo sido condenados a duras penas, de modo que, acaso postos em liberdade, invariavelmente não se colocarão de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva dos sentenciados.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados.

Arcarão os condenados com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06